Autos: 0801148-77.2018.8.12.0032
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor:Marcelo Pereira
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos.

Marcelo Pereira ajuizou ***"ação de obrigação de fazer com pedido tutela provisória de urgência"*** em desfavor de **Estado de Mato Grosso do Sul** e **Município de Deodápolis/MS.**

Em síntese, alegou a parte autora que é portador de Linfedema (CID I 89.0). Devido ao quadro clínico do paciente, fora solicitado pela médica que o acompanha Dr. Valdinei B. de Souza (CRM/MS 4823) o seguinte medicamento de uso diário e contínuo: DIOSMIM 500 MG (1 comprimido de 12/12 horas). Além disso, deve fazer uso de meia elástica de alta compressão (30-40 mmhj). O autor é hipossuficiente, não possuindo recursos financeiros para custear as despesas com o tratamento, pois trata-se de medicamento e insumo (meia elástica) que demandam alto custo (R$ 342,02). Outrossim, o autor já procurou o Poder Público solicitando o fornecimento do fármaco e insumo prescrito, contudo não teve seu pleito atendido. Através do Ofício 36/2018 da Defensoria Pública foi solicitado o fornecimento do medicamento e insumo, sendo que em resposta foi informado que o medicamento e insumo prescrito não é disponibilizado na rede pública. Assim, não resta alternativa ao autor senão a busca da tutela jurisdicional para compelir os demandados a fornecer gratuitamente o medicamento DIOSMIM 500 MG (1 comprimido de 12/12 horas) e meia elástica de alta compressão (30-40 mmhj), para garantia de sua integridade física e mental, inclusive porque o não uso dos medicamentos poderá comprometer a vida e desenvolvimento do requerente.

Com base nesses fatos, formulou pedido, a título de tutela antecipada, para que o Estado seja compelido a providenciar, de imediato, o medicamento DIOSMIM 500 MG (1 comprimido de 12/12 horas) e da meia elástica de alta compressão (30-40 mmhj) e/ou outros fármacos que se fizerem necessários ao tratamento, internação hospitalar, intervenção cirúrgica, consultas, retornos e todos os demais procedimentos e tratamentos que se fizerem necessários, fixando-se pena pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no fornecimento do medicamento e/ou do tratamento pleiteado, ante o iminente risco de danos irreparáveis a sua saúde, e, se for o caso, bloqueio das verbas públicas para custear o seu tratamento (Art. 301, CPC). O pedido final é para confirmação da tutela. Requereu o benefício da gratuidade. Deu à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

A petição inicial (p. 1-15) veio acompanhada de documentos (p. 16-40).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer desfavorável ao pedido (p. 43-46).

Indeferido o pedido de tutela de urgência (p. 47-49).

Em contestação (p. 56-73), o Município de Deodápolis alegou o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

seguinte: preliminarmente, ilegitimidade passiva – doença não contemplada com medicamentos da atenção básica. No mérito, aduziu, em síntese, que a demanda não contém provas de tratamentos anteriores, com outros medicamentos disponibilizados pelo SUS. Como mencionado pelo NAT, não há o mínimo de informação sobre o tratamento anterior realizado pela Requerente. Os recursos do SUS são, notoriamente, escassos. Deferir-se, sem qualquer planejamento, benefícios para poucos, ainda que necessários, podem causar danos para muitos, consagrando-se, sem dúvida, injustiça. Sequer pode se considerar o Judiciário como uma via que possibilite que um paciente possa burlar o fornecimento administrativo de medicamentos, garantindo seu tratamento sem que se leve em consideração a existência de outros na mesma ou em piores circunstâncias. Compulsando os autos, observa-se que sequer houve o atendimento do primeiro requisito, isso porque, em que pese as p. 30-32, nas quais são acostadas um questionário preenchido pelo médico, o mesmo não satisfaz o requisito, pois, não demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento solicitado, assim como a justificativa de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia. O questionário apenas afirma que o remédio prescrito não é constante na rede básica de medicamentos, do mesmo modo, que não descreve o porquê, um medicamento fornecido pelo SUS seria ineficaz ao tratamento. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

Impugnação à contestação (p. 90-99).

O Estado de Mato Grosso do Sul alegou preliminar de ausência de citação (p. 76-88).

O Juízo determinou a regular citação do Estado (p. 126).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação e alegou o seguinte: preliminarmente, inépcia da petição inicial - formulação de pedido genérico e incerto; ompetência da União para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (tese do STF RE 855.178/SE – tema 793). No mérito, arguiu a aplicação da tese firmada pelo STJ no Resp 1.657.156/RJ (tema 106); ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento pleiteado; sendo assim, pleiteia pelo julgamento improcedente da demanda e, subsidiariamente, no caso de procedência: a) seja estipulada a obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada dos medicamentos e que seja autorizado o fornecimento com base no princípio ativo (art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99); b) não haja condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual (Súmula 421/STJ); c) seja o cumprimento da obrigação direcionado à União e, no caso de custeio pelo Estado, seja garantido o direito ao ressarcimento; d) no caso de execução forçada do julgado, não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde; e) em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em nome e CNPJ do Estado (p. 131-148). Juntou documentos (p. 149-215).

Em impugnação a contestação (p. 217-223), a parte autora refutou os argumentos defensivos e pleiteou pela procedência da demanda.

O Estado de Mato Grosso do Sul pugnou pelo julgamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

antecipado da demanda (p. 227; p. 237).

A parte requerente informou a desnecessidade de produção de outras provas (p. 229).

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, conforme prevê o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória, bem como de produção de outras provas, além da documental e do parecer do NAT.

Nossos Tribunais assim têm se pronunciado a respeito do julgamento antecipado: "*Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder*". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo).

A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: "*O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art.130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia*" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475).

Da preliminar de ilegitimidade de parte passiva suscitada pelo Município de Deodápolis:

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é obrigação de todos entes da federação, o que abrange União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Esta é a determinação da Constituição Federal a respeito: *"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Com efeito, o mandamento legal impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que visam à prevenção, redução e recuperação de doenças. E tal comando, quando se refere ao Estado, abrange todos os entes políticos, quais sejam, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que integram o Sistema Único de Saúde com vistas à integralidade da assistência à saúde. Ademais, o art. 23, inciso II, da Constituição Federal dispõe que é competência comum da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal promoveram a saúde da população, estabelecendo, portanto, uma solidariedade obrigacional. Este é o entendimento da jurisprudência acerca do assunto:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL – SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ARGUIÇÃO REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO IMPROVIDO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem*

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva a garantia do acesso a serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde. Precedentes do STJ e STF. Preliminar rejeitada. (...) (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405400-73.2018.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 08/08/2018, p: 10/08/2018) (g.n).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO GRATUITO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS – MANIFESTA NECESSIDADE – DEVER DO ESTADO EM SENTIDO LATO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – ADMITIDA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOÁVEL – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõe ao Estado e ao Município, de modo solidário (art. 196, da CF), a obrigação de fornecer tratamento médico em favor de pessoas carentes, que comprova a necessidade do tratamento por prescrição médica. 2. Comprovada a necessidade de pessoa, sem recursos financeiros, do medicamento e não tendo sido tal fornecido na Rede Pública de Saúde, por entraves burocráticos, há que se proteger a prerrogativa fundamental de inviolabilidade do direito à vida. (...) (TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0800434-60.2017.8.12.0030, Brasilândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 07/08/2018, p: 09/08/2018) (g.n).

A Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º que *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.*"

E, no artigo 7.º, aduz que *"As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde SUS,são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".*

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, independentemente da condição financeira, à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade.

O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado eventualmente através de entraves burocráticos, questões referentes à competência deste ou daquele órgão. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana.

O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior.* ***Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana.*** *(...) (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA QUE ATENDE A PACIENTE INTERESSADA. DEVER DO ENTE ESTATAL LATO SENSU. PESSOA CARENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO PODEM SE*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

> *SOBREPOR AO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO E OBRIGATÓRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do município, porquanto os entes federativos são solidariamente responsáveis pela promoção e proteção da saúde de todos, ex vi do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Mantém-se a sentença que julgou procedente a inicial, determinando que o Município de Naviraí forneça os medicamentos pleiteados na Ação Civil Pública epigrafada, tendo em vista que é* ***dever do estado lato sensu disponibilizar tratamento e/ou medicamento àqueles que necessitam, não havendo falar em violação aos princípios da igualdade, da integralidade, da reserva do possível e muito menos da separação dos poderes.*** *(...) (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0802056-85.2014.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 28/03/2017, p: 30/03/2017).*

Ainda, não se pode olvidar que o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo *"conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público"*, a teor do que dispõe o art. 4.º, caput, da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, de molde que é dever dos Entes Federativos garantir o direito à saúde, independentemente de qualquer regulamento que, por sua vez, deverá sempre observar a regra constitucional.

Portanto, conclui-se que cabe ao Poder Público cumprir o seu dever constitucional de proporcionar aos pacientes em geral os mecanismos necessários para conferir-lhe tratamento adequado à sua enfermidade.

Logo, sendo obrigação solidária de todos os entes da federação brasileira o dever cravado no artigo 196 da Constituição da República, não merece acolhimento a preliminar ventilada.

Preliminar de inclusão da União no polo passivo da demanda:

Inicialmente, analiso a **preliminar de inclusão da União no polo passivo da demanda,** em observância ao tema 793, do STF.

Cumpre rememorar que o direito à saúde constitui obrigação do Estado, como um ente único, que se reparte nos três níveis da Federação, cuja responsabilidade é solidária. Não servem de contra-argumento alegações fundadas em distribuição de obrigações dentro do Sistema Único de Saúde. Perante o cidadão, a obrigação é do Estado, como uma entidade única, sendo-lhe lícito acionar aquele que lhe estiver ou parecer mais próximo ou mais acessível. Entre as esferas governamentais, resolve-se a questão por meio de repasses de recursos ou outras compensações.

Sobre o eixo temático, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se dizendo que *"Tratando-se de hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo, promovida pelo demandado, não comporta interpretação extensiva para alcançar prestação de entrega de coisa certa, cuja satisfação efetiva não comporta divisão"* (STJ, REsp 1125537-SC, 1ª Turma, Rel. Min.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

Teori Albino Zavascki, j. 16.03.2010, Dje. 24.03.2010)

Quanto à aplicação do TEMA 793, tem-se que foi fixada a tese, segundo a qual: "*Os **entes da federação**, em decorrência da competência comum, **são solidariamente responsáveis** nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial **direcionar o CUMPRIMENTO** conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (grifo nosso).*

Neste julgamento, não há dúvidas de que o STF confirmou entendimento anterior de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde.

Entretanto, não se pode impor à parte requerente que ingresse com a ação em face dos três entes federados obrigatoriamente, cabendo-lhe a escolha contra quem litigar, nos termos da legislação civil (art. 275, CC). Cabe à parte escolher em face de quem proporá a ação, não estando obrigada a demandar contra um ente específico, podendo, inclusive, acionar o Estado, Município e União conjuntamente.

Sabe-se que o litisconsórcio será obrigatório quando houver lei determinando a sua formação ou quando a natureza da relação jurídica exigir, o que não se aplica nesse caso, dado a ausência de complexidade da presente demanda e o baixo custo da obrigação.

Ante as ilações expostas, não há motivo para se determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e o deslocamento de competência para a Justiça Federal, uma vez que a solidariedade entre os entes federados no que diz respeito ao atendimento das ações de saúde não implicam litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo ao autor eleger contra quem demandar.

Quanto à divisão de atribuições e o dever de concessão de medicamentos, relevante consignar que competirá aos entes públicos decidirem administrativamente entre si acerca da responsabilidade pelo fornecimento.

Salienta-se que não foi possível consultar, no sítio do STF, o inteiro teor do julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sendo possível apenas analisar a ementa do julgamento.

Com base nesta análise, entende-se que não há como aplicar o referido Tema se a ação foi ajuizada apenas em face do Estado, eis que o **direcionamento** diz respeito ao **cumprimento da obrigação,** o que pressupõe que a ação tenha sido ajuizada em face de mais de um ente federado.

Nesta hipótese, será possível direcionar o cumprimento da obrigação a quem deve suportar o ônus conforme as regras de distribuição de competência determinadas pelo SUS.

Contudo, no presente caso a situação é diversa porque a ação foi ajuizada somente em face do Estado, não havendo como direcionar o cumprimento da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

obrigação em face de terceiro (União) que não integrou a lide.

Ainda, não se pode olvidar que o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo *"conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público"*, a teor do que dispõe o art. 4º, *caput*, da Lei n. 8.080/90, de modo que é dever dos entes federativos garantir o direito à saúde, independentemente de qualquer regulamento que, por sua vez, deverá sempre observar a regra constitucional.

A alegação do Estado para o reconhecimento da solidariedade mitigada não merece prosperar, haja vista que o RE n. 855.178/SE – *repercussão geral - Tema n. 793* não aborda a interpretação ventilada pela parte requerida, eis que fixou entendimento que é solidária a responsabilidade dos entes federados *(União, Estados e Municípios)* quanto à obrigação de fornecimento de serviços de saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, *verbis*:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.* ***O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade solidária entre os entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente****. (STF. RE n. 855.178/SE – Tema 793; Rel. Min. Luiz Fux; julgado em 05/03/2015) – grifos nossos.*

Logo, todos os entes da Federação são igualmente responsáveis pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. O repasse, se for o caso, deve ser objeto de ação própria.

Feitas tais considerações, entendo que não cabe ao caso a aplicação do Tema 793 em comento, cabendo o feito prosseguir apenas em relação à parte requerida.

Ressalta-se que não há necessidade de determinação judicial reconhecendo o direito de regresso, o qual decorre *ex lege*, em razão da solidariedade reconhecida constitucionalmente.

Da preliminar de inépcia da inicial:

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Isso porque, é possível a formulação de pedido genérico na ação em que se busca tratamento de saúde, por estar tal tratamento sujeito a constantes transformações em razão das modificações do quadro clínico do paciente (TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0800593-96.2019.8.12.0041, Ribas do Rio Pardo, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 19/11/2020, p:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

22/11/2020).

Mérito:

Trata-se de ação de conhecimento na qual a requerente aduz padecer de doença de Linfedema (CID I 89.0) e devido à sua enfermidade necessita do medicamento DIOSMIM 500 MG (1 comprimido de 12/12 horas) e da meia elástica de alta compressão (30-40 mmhj).

Para tanto, argumenta que, não possui condições econômicas de suportar o custo do medicamento sem comprometer sua renda e de sua família. O medicamento não é disponibilizado pelo SUS.

O pedido esboçado pela parte autora não merece acolhimento.

A apreciação do pedido de disponibilização de medicamentos exige cautela, sob pena de imputar consequências irremediáveis ao jurisdicionado e/ou interferir na esfera de competência do Executivo, porquanto, em sendo a saúde um dever, cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos, em especial àqueles sem recursos econômicos, o acesso universal e igualitário à assistência médica e farmacêutica.

De início, cumpre anotar que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao pleito, concluindo que (p. 45-46):

> *"XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.*
> *Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS;*
> *Considerando que Diosmina + Hesperidina não está padronizada na RENAME;*
> *Considerando que nas UBS são oferecidos Ácido Acetilsalicílico, Heparina e Varfarina;*
> *Considerando que não há informações sobre tratamentos anteriores, não foram apresentados resultados de exames complementares;*
> *Considerando as evidências científicas descritas no item III;*
> *Considerando que as meias de compressão não constam na tabela SIGTAP, portanto não são fornecidas pelo SUS;*
> *Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Diosmina + Hesperidina e meias de compressão.*

Importante registrar que, por força do julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 que tramita pelo rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema relativo à *"obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)*", determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, inc. II).

O referido recurso foi julgado, sendo firmada a seguinte tese de que *"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:* ***(i)*** *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ***(ii)*** *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;* ***(iii)*** *existência de registro na ANVISA do medicamento" (STJ, Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, Tema 106, Publicado em 04/05/2018).*

Dito isto, anoto que, para concessão de fármacos não disponibilizados pela rede pública de saúde, tampouco padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), os mencionados requisitos devem ser integralmente preenchidos.

No tocante ao medicamento e meias de compressão pleiteados, verifica-se a ausência de preenchimento do primeiro requisito, eis que, apesar de os documentos médicos de p. 28-32 prescreverem tal medicamento, devidamente registrado na ANVISA, trata-se de documento em que não comprova a imprescindibilidade e a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

Dessa forma, apesar de nos referidos documentos médicos o profissional ter indicado a necessidade de utilização do fármaco pleiteado e da meia elástica não restou fundamentada a impossibilidade de substituição por outros, fornecidos pelo SUS, tampouco a sua indispensabilidade para realização do tratamento.

No presente caso, **não há laudo médico fundamentado e circunstanciado**, mas apenas os documentos das p. 18-29 e o questionário das p. 30-32, onde o médico Valdinei B. de Souza, CRM/MS n. 4823 limita-se a apontar a doença diagnosticada e a necessidade do medicamento e da meia elástica receitados, não sendo apresentado fundamento sólido sobre o porquê de não ser possível a utilização dos medicamentos oferecidos pelo SUS.

Como apontado pelo parecer do NAT, (p. 45, item IX), *"Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) são oferecidos Ácido Acetilsalicílico, Heparina e Varfarina. O SUS oferece tratamento cirúrgico e esclerosante para varizes."*

Com efeito, no laudo médico de p. 30-32 não há informações sobre tratamentos anteriores e, conforme listado pelo NAT, existem outras alternativas para substituição do fármaco pleiteado (p. 45, item IX).

Dessa forma, verifica-se que a parte autora não trouxe nenhum documento que ateste a sua impossibilidade de fazer o uso dos medicamentos e tratamentos disponibilizados pelo SUS, com exceção ao questionário preenchido pelo médico, deve ser considerado que o SUS oferece, substâncias que a parte autora sequer mencionou já ter feito o uso.

Tal fato demonstra que a requerente não fez uso dos medicamentos fornecidos pela rede pública e indicados pelo parecer do NAT como alternativa, restando patente a necessidade de serem utilizados primeiramente, para que então, seja possível chegar-se à conclusão a respeito de sua eficácia ou não no controle da enfermidade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

Assim, conclui-se que não houve o esgotamento das alternativas disponíveis no sistema público de saúde, sendo que a parte requerente não informou o uso de medicamentos disponíveis no SUS para tratamento da enfermidade descrita na inicial.

Nesse aspecto, tem-se que o profissional médico responsável pelo atendimento da autora limitou-se a receitar o fármaco e a meia elástica sem que, contudo, houvesse sido utilizados os outros medicamentos disponibilizados pelo SUS e destinados ao tratamento da mesma patologia, tampouco fundamentada eventual impossibilidade de serem utilizados.

Nesse caminhar, considerando ausência de comprovação quanto à essencialidade do medicamento e da meia elástica prescritos para tratamento do autor e quanto ao esgotamento das alternativas medicamentosas oferecidas pelo SUS, as quais podem se mostrar eficazes na contenção das doenças, entendo não ser prudente conceder, no presente momento, o medicamento e a meia elástica receitados pelo profissional de saúde.

Apesar de o profissional médico indicar, como regra, o melhor tratamento que aprouver ao paciente, utilizando-se de todos os meios ao seu alcance para efetivar o direito à saúde, no caso concreto o médico responsável pelo atendimento do autor deixou de fundamentar os motivos pelos quais prescreveu medicamentos diferentes dos ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde.

Não obstante o direito à saúde, o tratamento a ser disponibilizado não deve ficar ao livre arbítrio do paciente ou de determinado profissional da área médica, sem que se demonstre que o medicamento pretendido é o único ou o mais apto para a finalidade indicada, especialmente quando o ente público disponibiliza opção terapêutica que alega satisfatória.

Inclusive, em momento algum constou do laudo médico que as substâncias receitadas pelo NAT como passíveis de controlar a doença do autor e ainda não utilizadas por ela, são impróprias, inadequadas ou não produzem os efeitos adequados ao tratamento da patologia.

Sobre o tema, o Enunciado n. 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiçam, realizada em 15 de maio de 2014 – São Paulo/SP, preconiza que *"nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS"*, o que, frise-se, não foi feito no caso em testilha.

Nesse sentido, o direito à saúde, que foi definido pela Constituição da República como um direito fundamental da pessoa humana, deve ser levado à sério, tanto pelo Estado quanto pelos profissionais que atuam no sistema de saúde pública ou privada, cuja atuação deve ser pautada pela medicina baseada em evidências e não mais na medicina baseada na autoridade.

Não se pode olvidar, ainda, que demonstrando a autora a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

necessidade do remédio (fato constitutivo de seu direito) e o réu, a possibilidade de sua substituição por outros (fato modificativo/impeditivo), incumbe à primeira a demonstração da impossibilidade da substituição, o que não ocorreu.

Quanto à idoneidade do posicionamento do NAT, é sabido que tal núcleo de apoio foi criado com a finalidade assessorar o Poder Judiciário Estadual, contribuindo com informações técnicas, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo órgão de natureza consultiva.

Portanto, sua função é conferir ao julgador maiores elementos técnicos necessários ao desfecho das lides, sem que o magistrado esteja vinculado aos seus pareceres, os quais são isentos de qualquer parcialidade.

Seguindo tal linha intelectiva, somente devem ser afastadas as orientações do NAT em situações em que resta demonstrada a imprescindibilidade justificada para a utilização de medicamentos diversos do protocolo clínico estabelecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diversamente do que ocorreu no caso em tela.

Nesse aspecto, percebendo-se do conjunto dos autos que o fármaco e meia elástica objetos do pedido não são de natureza essencial ao caso do requerente, tal fato recomenda a manutenção da conclusão negativa do parecer confeccionado pelo NAT.

Ademais, nada impede que, após a utilização dos fármacos dispensados pelo SUS e preceituados pelo referido parecer do NAT como eficazes no tratamento da doença da requerente, o autor faça novo pedido com fundamento na posterior constatação de ineficácia no controle de sua enfermidade.

A respaldar o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, é necessária a demonstração de que os fármacos fornecidos pelo Poder Público não foram eficazes para o tratamento, tem-se os seguintes julgados:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO - REsp n. 1.657.156-RJ – DESNECESSIDADE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – AUSENTES – MEDICAMENTO QUE PODE SER SUBSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. Considerando-se que a agravante pugna pela apreciação da medida de urgência, não há falar em suspensão na presente fase processual em razão do REsp n. 1.657.156-RJ. Quando o medicamento pleiteado pode ser substituído por outro que é disponibilizado pelo SUS e o tratamento sequer foi buscado pelo autor, ausente a probabilidade do direito". (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1412986-98.2017.8.12.0000, Ribas do Rio Pardo, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 04/04/2018, p: 10/04/2018) (g.n).*
>
> *"REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESP. N.º*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) De acordo com a tese fixada no REsp n. 1.657.159, "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da ***imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS****; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800344-50.2016.8.12.0042, Rio Verde de Mato Grosso, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 13/08/2018, p: 15/08/2018) (g.n).*

Ademais, cumpre dizer que para a inclusão de medicamento na RENAME é feita a comparação de medicamentos que tenham finalidades semelhantes quanto à sua eficácia e custo comparativo, decidindo-se, então, por aquele que apresente resultados mais positivos e abrangentes. Mas isso após passar por uma ***análise das evidências cientificas que são avalizadas por uma metanálise com resultados não conflitantes ou oriundas de estudos de rigor cientifico com número relevante de pacientes com grupo de controle e randomização***.

Portanto, o papel do Poder Judiciário, em casos como o presente que buscam o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público não pode se desviar das diretrizes e da Política Pública de Medicamentos, sob pena de usurpar a competência do Poder Executivo e prejudicar não só a saúde da própria parte requerente, através da concessão do medicamento pedido segundo entendimento deste ou daquele médico, desconsiderando a existência de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que estão baseados em evidências científicas, mas também todo o Sistema Público de Saúde que depende da regulação estatal para manter a atenção básica e avançada de saúde em todas as suas frentes.

Na hipótese, portanto, diante da ausência de demonstração nos autos de que a parte autora tenha feito uso dos fármacos padronizados e fornecidos pelo SUS e que estes tenham sido ineficazes, inexistindo justificativa médica plausível para a utilização do tratamento pleiteado, em vez do fornecido pelo SUS, **não comporta acolhimento o pedido de concessão do medicamento Diosmim 500 MG e da meia elástica de alta compressão (30-40 mmhj).**

Dispositivo:

Posto isso, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **improcedente** o pedido, tornando-se definitiva a decisão de p. 47-49, pela qual denegou-se o pedido de tutela de urgência.

Condena-se a parte requerente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, haja vista o zelo profissional, os atos processuais realizados, a natureza da demanda e o tempo na prolação da sentença. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte devida pela requerente, vez que goza dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.

benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Publique-se a Sentença, registrada automaticamente pelo SAJ.

Intimem-se a DPE, a PGE e o Município requerido, dando-se-lhes vista dos autos, pelo SAJ.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo modificação da presente decisão, arquivem-se os autos, com baixa.

Às providências.

Deodápolis, data da assinatura digital.

Vitor Dias Zampieri
Juiz de Direito em Substituição Legal
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 25/06/2022 às 13:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801148-77.2018.8.12.0032 e código P4ZwpvLU.